

第1編 ■ 序論

第1章 刑事訴訟法の意義 第2章 刑事訴訟法の目的 第3章 刑事訴訟法の構造

刑事訴訟法

No.1

H18-21

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【文章】は、刑事訴訟法の基本構造と審理・判決の対象との関係について述べた一つの見解である。①から⑧までの()内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。なお、同じ語句を2回以上用いてもよい。

【文 章】

いわゆる旧刑事訴訟法(大正11年法律第75号。後記昭和23年法律第131号により全面改正。以下「旧法」という。)においても、公訴の提起は検察官の職務であり、検察官が起訴の対象としての犯罪事実を示していた。しかし、旧法は、(①)主義の基本構造を採用しており、裁判所には、検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られることなく、これと(②)の同一性のある事実について、起訴状の記載の変更を経ることなく審理・判決する権限と責務があると考えられていた。つまり、起訴状において検察官が示した犯罪事実がそのままの形で審理・判決の対象になるとは限らず、実際に、窃盗の起訴に対して強盗を認定したり、住居侵入の起訴に対して住居侵入・窃盗を認定して、有罪判決をするようなことが行われていた。

これに対し、現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「現行法」という。)は、(③)主義の基本構造を採用し、訴因の制度を導入した。裁判所には、当事者たる検察官が起訴状に記載した訴因についてのみ、審理・判決する権限と責務があり、起訴状に記載された訴因と(④)の同一性のある事実であっても、検察官が訴因を変更しない限り、裁判所はこれについて審理・判決することはできないと考えられるようになった。実務では、住居侵入・窃盗につき住居侵入の部分で「吞んで」窃盗だけを起訴したり、強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として起訴するようなことが行われている。これは、(⑤)主義を徹底した現行法の下では、裁判所の認定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じることがあり得ることは、現行法が当然の前提としていえると考えられるからである。

裁判所の訴因変更命令に関しては、裁判所にその(⑥)を認めるべき場合があるかどうか論じられている。裁判所の訴因変更命令は、立証の対象に関する職権行使という点で、立証の過程における職権行使である職権証拠調べと似ているが、職権証拠調べの権限が、真実の解明とともに被告人保護のために用いられるのに対し、訴因変更命令は、特に被告人に利益を与える制度ではないこと、職権証拠調べは当事者の立証活動を排除しないのに対して、訴因変更命令は検察官の設定した審判の対象を修正しようとするものであることからみて、訴因変更命令と現行法の基本構造である(⑦)主義との間には鋭い緊張関係がある。したがって、裁判所に訴因変更命令の(⑧)まで認めるのは適当でない。

【語句群】

- a. 起訴状一本 b. 被疑事実 c. 直接 d. 当事者 e. 公訴事実
f. 裁量 g. 口頭 h. 義務 i. 職権
1. ①i③d 2. ①c⑧h 3. ③a④e 4. ⑤g⑥f 5. ④b⑧h

() には順に、① = i、② = e、③ = d、④ = e、⑤ = d、⑥ = h、⑦ = d、⑧ = h と入る。よって、() 内に適切な語句を入れた場合、組合せとして正しいものは、「① i ③ d」であり、従って、正解は肢 1 となる。

完成全文

いわゆる旧刑事訴訟法（大正 11 年法律第 75 号。後記昭和 23 年法律第 131 号により全面改正。以下「旧法」という。）においても、公訴の提起は検察官の職務であり、検察官が起訴の対象としての犯罪事実を示していた。しかし、旧法は、(① i. 職権) 主義の基本構造を採用しており、裁判所には、検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られることなく、これと (② e. 公訴事実) の同一性のある事実について、起訴状の記載の変更を経ることなく審理・判決する権限と責務があると考えられていた。つまり、起訴状において検察官が示した犯罪事実がそのままの形で審理・判決の対象になるとは限らず、実際に、窃盗の起訴に対して強盗を認定したり、住居侵入の起訴に対して住居侵入・窃盗を認定して、有罪判決をするようなことが行われていた。

これに対し、現行刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号。以下「現行法」という。）は、(③ d. 当事者) 主義の基本構造を採用し、訴因の制度を導入した。裁判所には、当事者たる検察官が起訴状に記載した訴因についてのみ、審理・判決する権限と責務があり、起訴状に記載された訴因と (④ e. 公訴事実) の同一性のある事実であっても、検察官が訴因を変更しない限り、裁判所はこれについて審理・判決することはできないと考えられるようになった。実務では、住居侵入・窃盗につき住居侵入の部分を「吞んで」窃盗だけを起訴したり、強盗致傷について傷害が軽微なので単に強盗として起訴するようなことが行われている。これは、(⑤ d. 当事者) 主義を徹底した現行法の下では、裁判所の認定が検察官の設定した訴因に拘束されて実体的真実との乖離を生じることがあり得ることは、現行法が当然の前提としていると考えられるからである。

裁判所の訴因変更命令に関しては、裁判所にその (⑥ h. 義務) を認めるべき場合があるかどうかが論じられている。裁判所の訴因変更命令は、立証の対象に関する職権行使という点で、立証の過程における職権行使である職権証拠調べと似ているが、職権証拠調べの権限が、真実の解明とともに被告人保護のために用いられるのに対し、訴因変更命令は、特に被告人に利益を与える制度ではないこと、職権証拠調べは当事者の立証活動を排除しないのに対して、訴因変更命令は検察官の設定した審判の対象を修正しようとするものであることからみて、訴因変更命令と現行法の基本構造である (⑦ d. 当事者) 主義との間には鋭い緊張関係がある。したがって、裁判所に訴因変更命令の (⑧ h. 義務) まで認めるのは適当でない。

① i ③ d ⑤ d

まず、旧法と現行法の基本構造について言及する①と③・⑤に入る語句について検討する。刑事訴訟法の基本構造については、大きく分けて職権主義と当事者主義の2つの考え方がある。職権主義とは、裁判所が訴訟の追行（審判対象の設定と証拠による立証）の責任を負うとする原則をいい、当事者主義とは、当事者（検察官と被告人）が訴訟の追行の責任を負うとする原則をいう。そうすると、①と③・⑤には d 又は i が入ることになる。そして、旧法は職権主義を採用して裁判所に訴訟追行の主導権を与えていたが、現行法は当事者主義を採用して当事者に訴訟追行の主導権を与えた（起訴状一本主義についての 256 条 6 項、証拠調べ請求権についての 298 条 1 項、訴因変更請求権についての 312 条 1 項参照）。したがって、①には i、③・⑤には d が入ることとなる。

② e ④ e

次に、②に入る語句について検討する。ここに入る可能性のある語句は「b. 被疑事実」又は「e. 公訴事実」である。そして、「b. 被疑事実」は捜査段階における用語であって起訴後には用いられないため、入りえない。一方、「e. 公訴事実」とは公訴において示される犯罪事実のことをいう。旧法では、職権主義の基本構造から、審判の対象は検察官が起訴状に記載した犯罪事実に限られず、その背後にある生の事実である公訴事実そのものとされていた。したがって、旧法下について述べる②に入る語句は、「e. 公訴事実」となる。これに対し、現行法では当事者主義の基本構造から審判の対象は検察官が設定した訴因に拘束され、公訴事実の同一性がある事実であっても検察官の訴因変更請求なくしては審理・判決できない（訴因変更請求権についての312条1項及び不告不理の原則についての378条3号後段参照）。また、②の場合と同様、後に「の同一性」と続くものは「e. 公訴事実」しかない。したがって、④に入る語句も、「e. 公訴事実」となる。

⑥ h ⑦ d ⑧ h

⑥～⑧に入る語句について検討する。まず、⑦は現行法の基本構造について指摘するものであるから、③・⑤の場合と同様に、「d. 当事者」（主義）が入る。次に、⑥と⑧について検討すると、「裁判所の訴因変更命令」に関して、裁判所に何らかの権限あるいは責務について述べるものであるから、同一の語句が入る。ここに入る可能性のある語句は「f. 裁量」又は「h. 義務」であるところ、裁判所の訴因変更命令権は312条2項により明文で認められており、本見解でも「職権行使」を前提としているため、裁量があることにつき解釈上争いとなる余地はないから、「f. 裁量」は入りえない。他方、「h. 義務」についてみると、訴因変更命令は、職権証拠調べとの比較上、被告人保護のための制度でないことや検察官の権限を修正するものであることを理由に、当事者主義との緊張関係があることを本見解では述べている。かかる見解からは、当事者主義の補完としての職権証拠調べとは異なり、訴因変更命令においては義務化を認めないとの流れが読み取れる。したがって、⑥と⑧には「h. 義務」が入る。なお、判例（最決昭43.11.26）・通説は、原則として訴因変更命令義務を認めないが、（ア）犯罪の重大性、（イ）証拠の明白性を要件に例外的に訴因変更命令義務を肯定する。

